

המכללה האקדמית נתניה

בית הספר למשפטים

סמינריון מונחה במשפט פלילי

מיני סמינר

עבירת ההסתה לגזענות

בין מטרת המפרסם לתוכן הפרסום, ושאלת הלכת הצפיות שטרם הוכרעה

מגיש/ה: _____

ת"ז: _____

מנחה: ד"ר עו"ד גלית אהרון

מועד הגשה: 20.10.2026

תוכן עניינים

1.....	מבוא
1.....	פרק א: רקע ותכלית
2.....	פרק ב: המסגרת הנורמטיבית
3.....	פרק ג: יסודות העבירה בפסיקה
3.....	1. פרשת אלבה: מטרה או תוכן?
4.....	2. פרשת העברי: הקשר שמשלים את התוכן
4.....	3. פרשת סלאח: הסתה ברמז
5.....	4. בג"ץ "תורת המלך": גבולות הסייג הדתי
6.....	פרק ד: היסוד הנפשי ושאלת הלכת הצפיות
7.....	פרק ה: חופש הביטוי ומבט משווה
8.....	פרק ו: ביקורת והצעות
8.....	1. האכיפה ושיקול הדעת של היועץ המשפטי
9.....	2. עקרון החוקיות
9.....	3. הרשתות החברתיות
10.....	4. דרכים שאינן פליליות
10.....	סיכום
11.....	רשימה ביבליוגרפית

מבוא

סעיף 144ב(א) לחוק העונשין קובע: "המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות, דינו – מאסר חמש שנים".¹ הסעיף נחקק ב-1986, ומאז הוגשו לפיו כתבי אישום ספורים בלבד. ובכל זאת, כמעט כל הליך מרכזי שנפתח לפיו הגיע לבית המשפט העליון והשאיר אחריו מחלוקת. השאלות שבמחלוקת נוגעות ללב העבירה: האם אפשר להרשיע אדם בגלל טקסט שאינו גזעני על פניו, אם הוכח שרצה להסית? האם די בכך שצפה שדבריו יסיתו, גם אם לא זו הייתה מטרתו? ואיך איסור פלילי על ביטוי מתיישב עם חופש הביטוי?

אבחן את השאלות האלה דרך ארבעה הליכים. פרשת אלבה (1996) עיצבה את יסודות העבירה. פרשת העברי (2005) עסקה בהחזקת חולצות שעליהן סיסמה גזענית. בג"ץ "תורת המלך" (2015) דן בהחלטה שלא להעמיד לדין את מחברי ספר הלכתי, ופרשת ראאד סלאח (2016) הסתיימה בהרשעה של מנהיג דתי בגלל דרשה. שאלת המחקר היא אם העבירה, כפי שהיא מנוסחת ומפורשת היום, מגדירה בבהירות מספקת מה אסור, ואם היא מאזנת כראוי בין ההגנה על כבוד האדם ועל השוויון לבין חופש הביטוי.

הטענה שלי כפולה. בשאלת היסוד העובדתי הפסיקה הגיעה לאיזון סביר, כשאימצה בפועל את הדרישה שהטקסט עצמו יבטא הסתה לגזענות. בשאלת היסוד הנפשי המצב שונה: כבר שלושים שנה לא הוכרע אם הלכת הצפיות חלה על העבירה, ואי-הוודאות הזו פוגעת בעקרון החוקיות ומשפיעה גם על מדיניות האכיפה. בפרק האחרון אציע להכריע בשאלה ולהחיל את הלכת הצפיות, לצד דרישת התוכן האובייקטיבי וההגנה שסעיף 144ג לחוק נותן לדיווח ולציטוט.

העבודה בנויה כך. פרק א מציג את הרקע לחקיקה ואת תכליותיה. פרק ב מתאר את סעיפי החוק ומבחין בין העבירה לבין עבירות קרובות. פרק ג מנתח את ארבע הפרשות, ובמרכזו המחלוקת בפרשת אלבה בשאלה אם די במטרת המפרסם או שנדרש גם תוכן מסית. פרק ד עוסק ביסוד הנפשי ובשאלת הלכת הצפיות. פרק ה בוחן את היחס לחופש הביטוי ומשווה לשיטות משפט אחרות, ופרק ו מציג ביקורת והצעות לשינוי.

פרק א: רקע ותכלית

האיסור נוסף לחוק בתיקון מס' 20,² על רקע פעילותה של תנועת "כך" בראשות מאיר כהנא. שנה קודם לכן תוקן חוק-יסוד: הכנסת, ונוסף לו סעיף 7א, שלפיו רשימה שיש במטרותיה או במעשיה הסתה לגזענות לא תשתתף בבחירות.³ המחוקק פעל אפוא בשני מישורים, החוקתי והפלילי, נגד אותה תופעה. ברקע עמדה גם התחייבותה של ישראל לפי האמנה לביעור אפליה גזעית, שסעיף 4(א) שלה מחייב את המדינות להפליל הפצה של רעיונות בדבר עליונות גזעית והסתה לאפליה.⁴

¹ ס' 144ב(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין או החוק).

² חוק העונשין (תיקון מס' 20), התשמ"ו-1986.

³ ס' 7א לחוק-יסוד: הכנסת. לרקע ראו בג"ץ 399/85 כהנא נ' הוועד המנהל של רשות השידור, פ"ד מא(3) 255 (1987).

⁴ ס' 4(א) לאמנה הבין-לאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית, כ"א 25, 547 (נפתחה לחתימה ב-1966).

דנה מרשק-מרום מונה כמה תכליות לאיסור: הגנה על קיום המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, על כבוד האדם ועל השוויון בין בני האדם, ועל הסדר החברתי ושלוש הציבור. לדבריה, המרחק בין ביטויי גזענות לבין גילויי אלימות "אינו רב", ואידאולוגיה גזענית עלולה להסלים לפגיעה ממשית, בידי הדובר עצמו או בידי מי ששומע אותו.⁵ השופט מצא הגדיר בפרשת אלבה גזענות כ"כל שנאת חנם של הזר בשל היותו זר", על רקע שונות גזעית או לאומית-אתנית. הוא הדגיש שהחוק לא נועד להגן על מיעוטים בלבד אלא על כל קבוצה, ולכן גם הסתה לאנטישמיות נכנסת לגדר העבירה, אף שבישראל היהודים הם הרוב.⁶

פרק ב: המסגרת הנורמטיבית

סעיף 144א מגדיר גזענות כ"רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני".⁷ ההגדרה רחבה ואינה מוגבלת להבחנות ביולוגיות. כבר בפרשת ניימן קבע בית המשפט העליון ש"הרדיפה לצורותיה, שטעמיה הם לאומיים, כלולה בימינו במסגרת המשמעות המקובלת של התופעה של גזענות".⁸

סעיף 144ב(ב) מוסיף ש"אין נפקא מינה אם הפרסום הביא לגזענות או לא, ואם היה בו אמת או לא". השופט מצא למד מכך שזו "עבירה התנהגותית טהורה": לא נדרשת תוצאה, וגם לא נדרשת הסתברות שתתרחש.⁹ מול ההיקף הרחב של היסוד העובדתי עומדת דרישה נפשית מחמירה, "מטרה להסית", שבה אעסוק בפרק ד.

שני סייגים מצמצמים את האיסור. סעיף 144ג(א) מתיר פרסום של דין וחשבון נכון והוגן על פרסום אסור, וסעיף 144ג(ב) מתיר ציטוט מכתבי דת ומספרי תפילה וקיום פולחן דתי. שני הסייגים חלים רק אם הפרסום לא נעשה במטרה להסית.¹⁰ לצד האיסור העיקרי, סעיף 144ד אוסר להחזיק פרסום גזעני לשם הפצה, וסעיף 144ה קובע שכתב אישום יוגש רק בהסכמה בכתב של היועץ המשפטי לממשלה. השופט בך העריך בפרשת אלבה שדרישת ההסכמה "תמנע שימוש רחב מדי" בסעיף.¹¹

כדאי להבחין בין העבירה לבין שלוש עבירות קרובות. עבירת ההסתה לאלימות שבסעיף 144ד דורשת במפורש "אפשרות ממשית" שהפרסום יביא למעשה אלימות. דרישה זו נוספה ב-2002, בין היתר לאחר הדיון בפרשת ג'בארין ביחס בין פרסום מסית לבין הסיכון הנובע ממנו.¹² עבירת ההמרדה שבסעיף 134 כוללת יסוד של "תוצאה בכוח", ובכך היא שונה מסעיף 144ב.¹³ סעיף 144ו אינו אוסר

⁵ דנה מרשק-מרום "התפתחותה של הסתה" 75 שנות עצמאות במשפט 570, 571 (דפנה ברק-ארז עורכת ראשית 2023).

⁶ ע"פ 2831/95 אלבה נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(5) 221, 256-257 (1996) (להלן: עניין אלבה).

⁷ ס' 144א לחוק העונשין.

⁸ ע"ב 1/88 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים-עשרה, פ"ד מב(4) 177, 191-192 (1988).

⁹ עניין אלבה, לעיל ה"ש 6, בעמ' 257.

¹⁰ ס' 144ג לחוק העונשין.

¹¹ ס' 144ד-144א לחוק העונשין; עניין אלבה, לעיל ה"ש 6, בעמ' 305.

¹² ס' 144ד לחוק העונשין; דנ"פ 8613/96 ג'בארין נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(5) 193 (2000).

¹³ עניין אלבה, לעיל ה"ש 6, בעמ' 276; ע"פ 6696/96 כהנא נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(1) 535 (1998).

ביטוי כלל. הוא מחמיר את העונש על עבירות אחרות שנעברו מתוך מניע של גזענות. ההבדל בין "מניע" לבין "מטרה להסית" משקף בחירה של המחוקק: מעשה שנעשה משנאה מוחמר, ואילו ביטוי נאסר רק כשהוא נועד להסית.¹⁴

פרק ג: יסודות העבירה בפסיקה

1. פרשת אלבה: מטרה או תוכן?

הרב עידו אלבה, מורה הלכה בכולל שליד מערת המכפלה, חיבר והפיץ מאמר בשם "בירור הלכות הריגת גוי". בית המשפט המחוזי הרשיע אותו בהסתה לגזענות ובעבירות נשק, והערעור נדחה בהרכב של שבעה שופטים, ברוב של חמישה נגד שניים.¹⁵ השופטים הסכימו על התוצאה, אבל נחלקו בשאלה מהותית: מה צריך להיות בטקסט עצמו.

השופט מצא, שכתב את חוות הדעת העיקרית, שם את מרכז הכובד במטרת המפרסם. לשיטתו, "אף פירסום שתוכנו אינו גזעני עשוי למלא את יסודה העובדתי של העבירה". התוכן חשוב כראיה למטרה, אבל אין צורך לפרש אותו כדי לקבוע שהיסוד העובדתי התקיים.¹⁶ היתרון שמצא ראה בגישה זו הוא שבית המשפט אינו נדרש להכריע בשאלות של דת ואמונה, למשל אם ערכיה של דת מסוימת כוללים ערך גזעני.¹⁷ את המטרה עצמה הסיק מצא מתוכן המאמר ומנסיבות הפצתו. הוא הוסיף שכאשר המחבר שותק ואינו מסביר את כוונתו, בית המשפט רשאי לקבוע את מטרתו לפי המסקנה העולה מהטקסט, ושהכותרת "לעיון ולא למעשה" אינה משנה את המסקנה.¹⁸

הנשיא ברק הגיע לאותה תוצאה בדרך אחרת. לדעתו, "הדבר שפורסם, על-פי מובנו לשומע, צריך לבטא הסתה לגזענות", ואין להסתפק במטרה אם הטקסט, "על-פי פירושו התכליתי על רקע הקשרו", אינו מסית. מובן הטקסט יכול לנבוע מתוכנו או מהנסיבות שבהן פורסם, אבל טקסט תמים אינו נעשה אסור רק בגלל המחשבה שמאחוריו.¹⁹ ברק הזהיר שענישה על אמירה תמימה שמלווה במטרה פסולה "מתקרבת קרבה מסוכנת להפרת הכלל האוסר על ענישת דברים שבלב", וקבע שענישה כזו חורגת מהמידה הדרושה.²⁰ השופטים טל וטירקל, שהיו בדעת מיעוט, ראו במאמר חיבור עיוני-הלכתי, והשופט טל הזהיר מפגיעה בחופש הביטוי האקדמי.²¹ בשאלת התוכן, לעומת זאת, הצטרפו לעמדת הנשיא ברק השופטים גולדברג, טל וטירקל, ולכן זו עמדת הרוב בפסק הדין, אף שחוות הדעת העיקרית נכתבה בידי מצא.

לדעתי גישתו של ברק עדיפה, והיא גם זו שנקלטה בפסיקה המאוחרת. בפרשת העברי, שתידון מיד, אימץ בית המשפט המחוזי כמעט מילה במילה את המבחן של "פירושו התכליתי על רקע הקשרו".

¹⁴ ס' 144 לחוק העונשין; מרים גור-אריה "זכויות אדם והמשפט הפלילי המהותי" משפטים נ 759, 765 ה"ש 23 (2021).

¹⁵ ת"פ (מחוזי י-ם) 251/94 מדינת ישראל נ' אלבה (נבו 12.4.1995); מרשק-מרום, לעיל ה"ש 5, בעמ' 571.

¹⁶ עניין אלבה, לעיל ה"ש 6, בעמ' 264–265, 270.

¹⁷ שם, בעמ' 265–266.

¹⁸ שם, בעמ' 270–273.

¹⁹ שם, בעמ' 294–295.

²⁰ שם, בעמ' 295–297.

²¹ מרשק-מרום, לעיל ה"ש 5, בעמ' 572.

היתרון המעשי של גישת מצא קטן ממה שנראה: גם לפיה המטרה מוכחת בעיקר מתוך התוכן, ולכן בית המשפט ממילא קורא את הטקסט ומפרש אותו. מול יתרון מוגבל זה עומד מחיר ממשי, כי הגישה מאפשרת להעניש על מחשבה בלבד.

2. פרשת העברי: הקשר שמשלים את התוכן

דוד העברי, פעיל ימין קיצוני, החזיק שק ובו עשרות חולצות שעליהן הכיתוב "אין ערבים – אין פיגועים" ודיוקנו של כהנא. בית המשפט המחוזי הרשיע אותו בהחזקת פרסום גזעני לפי סעיף 144ד. נקבע שהסיסמה "נוקטת בלשון מכלילה ומדברת על כלל הערבים", ושהדיוקן של כהנא, "שמשנתו ידועה", מחזק את אופייה הגזעני.²² בית המשפט הוסיף שכאשר מדובר בעשרות חולצות, ההסתברות שהמסר יופץ היא "קרובה לוודאי". יש בכך חשיבה ברוח הלכת הצפיות, והיא הופעלה בעבירה הנלווית אף שבעבירה העיקרית השאלה לא הוכרעה.

3. פרשת סלאח: הסתה ברמז

ב-2007, בימי המהומות סביב העבודות במעלה המוגרבים, נשא ראאד סלאח, ראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, דרשה בפני כאלף איש בוואדי ג'וז שבירושלים. בדרשה אמר: "אנו אף פעם לא הרשינו לעצמנו ללוש את הלחם של ארוחת שבירת הצום בחודש רמדאן המבורך בדמם של הילדים", והוסיף שמי שרוצה הסבר נוסף "שישאל מה היה קורה לחלק מהילדים של אירופה, אשר דמם היה מתערבב בבצק של הלחם הקדוש".²³ בית משפט השלום זיכה אותו מהסתה לגזענות, משום שהדברים לא היו בהירים דיים ונותר ספק באשר למודעותו. בית המשפט המחוזי הרשיע אותו, וקבע ש"אין מדובר בדיון תאולוגי שכלתני ומנותק" אלא בהעלאה מכוונת של עלילת דם.²⁴

בית המשפט העליון השאיר את ההרשעה על כנה. המשנה לנשיאה רובינשטיין הסיק את המטרה מהמכלול: מעמדו של הדובר, הקהל הגדול והנסער, הקרבה להר הבית, האווירה הנפיצה והעובדה שהדרשה הייתה מתוכננת. לדבריו, הבחירה להזכיר את "אחד מן הסמלים המובהקים ביותר לשנאת היהודים" ולכרוך אותו בקריאה להגן על מסגד אל-אקצא מובילה למסקנה שתכלית הדברים הייתה להסית.²⁵ הפרשה מלמדת שהעבירה חלה גם על רמיזה: סלאח לא האשים את היהודים במפורש, אלא הציג את הדברים כשאלה רטורית. היא מלמדת גם עד כמה קל יותר להוכיח את סעיף 144ב מאשר את סעיף 144ד. השופט ג'ובראן הסכים להרשעה בהסתה לגזענות, ונחלק על חבריו רק בעבירת ההסתה לאלימות, שבה נדרשת "אפשרות ממשית".²⁶

רשימת השיקולים שבית המשפט מנה לעניין ההסתה לאלימות, "מי אמר, מה נאמר, היכן נאמר, באיזה אופן נאמר, למי נאמר ובאיזו מסגרת נאמר", שימשה אותו בפועל גם להוכחת המטרה בעבירת

²² ע"פ (מחוזי י-ם) 8612/04 העברי נ' מדינת ישראל (נבו 4.5.2005).

²³ רע"פ 7669/15 מחאג'נה נ' מדינת ישראל, פס' ג לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין (נבו 18.4.2016) (להלן: עניין סלאח).

²⁴ שם, פס' ה, ט.

²⁵ שם; מרשק-מרום, לעיל ה"ש 5, בעמ' 573.

²⁶ עניין סלאח, לעיל ה"ש 23.

ההסתה לגזענות. גם בשאלת העונש יש בפרשה לקח. בית המשפט ציין שהמגמה בפסיקה היא להחמיר בעבירות הסתה על רקע אידאולוגי, "למען יראו וייראו", ושמעמדו של סלאח כמנהיג רוחני רב השפעה מחמיר את המעשה. עם זאת, בגלל חלוף הזמן ומדיניות הענישה שנהגה בעת האירוע, הופחת עונש המאסר בפועל מאחד עשר חודשים לתשעה.²⁷ ההליך נמשך כתשע שנים מיום הדרשה ועד פסק הדין בבית המשפט העליון. פרק זמן כזה מחליש את ההרתעה שבית המשפט עצמו ביקש להשיג, ומחזק את הטענה שאעלה בפרק ו על קשיי האכיפה.

4. בג"ץ "תורת המלך": גבולות הסייג הדתי

הספר "תורת המלך", שפורסם ב-2009, עוסק ב"דיני נפשות בין ישראל לעמים", ויש בו פרקים כמו "הריגת גוי שעובר על שבע מצוות" ו"פגיעה מכוונת בחפים מפשע". היועץ המשפטי לממשלה סגר את התיק נגד המחברים מחוסר ראיות. הוא נימק זאת בקושי להוכיח מטרה להסית בחיבור שהוא "בירור הלכתי", בכך שהספר עוסק ב"גויים" ולא בערבים דווקא, ובכך שאין בו קריאה לפעולה. המחברים עצמם טענו שהספר מוגן כ"פרסום ציטוט מתוך כתבי דת", והיועץ המשפטי קיבל טענה זו לפחות בחלקה.²⁸ העתירה נגד ההחלטה נדחתה בדעת רוב. המשנה לנשיאה רובינשטיין הבחין בין הספר לבין המאמר של אלבה, שהגיע למסקנה הלכתית ברורה המטילה חובה על האדם הפרטי, ושמחברו היה פעיל ברכישת נשק. עם זאת הדגיש שלחיבורים הלכתיים אין חסינות מוחלטת, וכתב שההכרעה ניתנה "בחירוק שיניים. לבי להעמדה לדין ומוחי בספקות הרבים".²⁹

קשה ליישב את התוצאה עם הלכת אלבה. גם מחברי "תורת המלך" שתקו בחקירה, וגם הם טענו שמדובר בעיון תיאורטי. באלבה נקבע שבמצב כזה בית המשפט רשאי להסיק את המטרה מהתוכן, ושכותרת עיונית אינה מחסנת את המפרסם.³⁰ גם הנימוק של "גויים" ולא "ערבים" חלש, שהרי לפי השופט מצא החוק מגן על כל קבוצה ולא על קבוצה מסוימת.³¹ גם ההסתמכות על סעיף 144ג(ב) אינה משכנעת. הסייג מגן על ציטוט מכתבי דת, ולא על חיבור חדש שמסיק מהמקורות מסקנות מעשיות בדבר הריגה. אילו כל חיבור שנשען על מקורות דתיים היה נהנה מהסייג, העבירה הייתה מתרוקנת מתוכן בדיוק בתחום שבו נולדה. נראה שההבדל בין הפרשות נובע בעיקר מסוג ההליך. באלבה בית המשפט עצמו שקל את הראיות במשפט פלילי. ב"תורת המלך" הוא רק בחן אם החלטת היועץ המשפטי אינה סבירה ברמה קיצונית, וציין שאין תקדים להתערבות בהחלטה שלא להעמיד לדין מחוסר ראיות.³²

²⁷ שם.

²⁸ בג"ץ 2684/12 "ב' בחשוון התנועה לחיזוק הסובלנות בחינוך הדתי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פס' ב, ז לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין (נבו 9.12.2015) (להלן: פרשת "תורת המלך").

²⁹ שם, פס' לב; מרשק-מרום, לעיל ה"ש 5, בעמ' 572–573.

³⁰ עניין אלבה, לעיל ה"ש 6, בעמ' 270–273.

³¹ שם, בעמ' 257.

³² פרשת "תורת המלך", לעיל ה"ש 28.

פרק ד: היסוד הנפשי ושאלת הלכת הצפיות

לפי סעיף 20(ב) לחוק, "לענין כוונה, ראייה מראש את התרחשות התוצאות, כאפשרות קרובה לוודאי, כמוה כמטרה לגרמן". הכלל נועד להתגבר על הקושי להוכיח מה רצה אדם כשפעל.³³ השאלה היא אם הכלל חל גם על "מטרה להסית" שבסעיף 144ב, שהיא עבירה התנהגותית.

בפרשת אלבה נחלקו השופטים גם בשאלה זו. השופט מצא סבר שאין הבדל בין "מטרה" בעבירה התנהגותית לבין "כוונה" בעבירה תוצאתית, ולכן סעיף 20(ב) חל. הוא הוסיף שהחלת הכלל רצויה, בגלל הקושי המיוחד להוכיח מטרה בעבירה שאין בה תוצאה, ומשום שלדעתו אין לאיסור אינטרס נגדי של ממש.³⁴ הנשיא ברק חלק עליו. לדעתו, "מטרה" בעבירה התנהגותית אינה "כוונה", ולכן סעיף 20(ב) אינו חל עליה מאליו. את השאלה אם להחיל את הכלל בדרך פרשנית יש לבחון בכל עבירה לפי תכליתה, ובסעיף 144ב התכלית מחייבת איזון בין חופש הביטוי והחופש האישי של המפרסם לבין אינטרס הציבור, כבוד האדם והשוויון. ברק ציין ש"איזון זה אינו פשוט כלל ועיקר", והשאיר את השאלה בצריך עיון.³⁵

מאז התגבשה בפסיקה עמדה כללית: בעבירות מטרה הלכת הצפיות אינה חלה אוטומטית, ויש לבחון כל עבירה לגופה.³⁶ בעבירת התרמית בניירות ערך נקבע שהכלל אינו חל, משום שהערך המוגן, תקינות שוק ההון, נפגע רק כשיש כוונה להשפיע על השער.³⁷ קרוב יותר לענייננו פסק הדין בפרשת ביטון, שבו קבע הנשיא ברק שהכלל אינו חל על עבירת לשון הרע. הנימוק היה שהערך המוגן, מניעת שנאה ושמירה על שלום הציבור, נפגע בעיקר כשיש כוונה לפגוע, ושהחלת הכלל תפגע קשות בחופש הביטוי, ובמיוחד בחופש של עיתונאים.³⁸

בפרשת תורת המלך חזר השופט ג'ובראן, בדעת מיעוט, לעמדתו של מצא. לדבריו, "אי-ההכרעה המתמשכת בשאלת החלת הלכת הצפיות בעבירת ההסתה לגזענות פוגעת בעקרון החוקיות", שאחת מנגזרותיו היא הדרישה שהחוק הפלילי יהיה ברור וודאי. הוא סבר שתכליות העבירה תומכות בהחלת הכלל, והציע להורות ליועץ המשפטי לבחון מחדש את הראיות תוך שימוש בו.³⁹

לדעתי יש להכריע בעד החלת הכלל. הטיעון מפרשת ביטון חזק, אבל אי אפשר להעביר אותו כמות שהוא לסעיף 144ב. השופט מצא הסביר שהערך המוגן בסעיף 144ב הוא "מניעתה של עצם ההסתה", וערך זה נפגע גם אם איש מהקוראים לא יפגע בפועל באחרים.⁴⁰ הפגיעה בכבוד ובשוויון נגרמת אפוא

³³ ס' 20(ב) לחוק העונשין; עניין סלאח, לעיל ה"ש 23; גיל עשת "הלכת הצפיות: יסודות של ודאות מול שיקול-דעת שיפוטי על רקע תיקון 39 לחוק העונשין" **עלי משפט** ג 617 (2003); יורם רבין ויניב ואקי **דיני עונשין** א 456–458 (מהדורה שלישית 2014).

³⁴ עניין אלבה, לעיל ה"ש 6, בעמ' 262, 281.

³⁵ שם, בעמ' 299–303.

³⁶ רות קנאי ורוני רוזנברג "הלכת הצפיות ועבירת הניסיון: הילכו שתייהן יחדיו?" **ספר יעקב וינרוט** 475, 484–485 (גרשון גונטובניק, אברהם וינרוט וחיים זיכרמן עורכים 2021).

³⁷ ע"פ 99/14 **מדינת ישראל נ' מליסרון בע"מ**, פס' נז לפסק דינו של השופט (כתוארו אז) רובינשטיין (נבו 25.12.2014); קנאי ורוזנברג, לעיל ה"ש 36, בעמ' 485.

³⁸ ע"פ 9818/01 **ביטון נ' סולטן**, פ"ד נט(6) 554, 579 (2005); קנאי ורוזנברג, לעיל ה"ש 36, בעמ' 484, 486 ה"ש 44.

³⁹ פרשת **תורת המלך**, לעיל ה"ש 28, פס' 24–25 לפסק דינו של השופט ג'ובראן.

⁴⁰ עניין אלבה, לעיל ה"ש 6, בעמ' 260.

מעצם הפצת המסר הגזעני, בלי קשר לשאלה אם המפרסם רצה בכך או רק ידע שזה כמעט ודאי יקרה. החשש לעיתונאים ולחוקרים מוצדק, אבל החוק כבר נותן לו מענה. ראשית, דרישת התוכן של ברק מסננת דיווח: כתבה שמצטטת דברי הסתה מבטאת, לפי מובנה לקורא, דיווח ולא הסתה. שנית, סעיף 144ג(א) מתיר במפורש דין וחשבון נכון והוגן. שלישית, הלכת הצפיות דורשת ראייה של התוצאה כאפשרות קרובה לוודאי, רף שדיווח עיתונאי רגיל אינו מגיע אליו. בזכות המסננים האלה אפשר להחיל את הכלל בלי להרחיב את העבירה מעבר לתכליתה.

פרק ה: חופש הביטוי ומבט משווה

מאז בג"ץ קול העם, הגבלה של ביטוי בשם שלום הציבור מותנית בדרך כלל ב"ודאות קרובה" לפגיעה.⁴¹ סעיף 144ב חורג מהכלל הזה. השופט מצא קבע שלמבחן הסתברותי "אין, ולא יכולה להיות, תחולה" בעבירה התנהגותית מובהקת, וכתב: "הביטוי הגזעני אינו נמנה עם צורות הביטוי הפוגעניות, המרגיזות או המקוממות, שעל חברה חופשית להשלים עם קיומן, חרף סלידתה מפניהן. הביטוי הגזעני הוא חריג. הוא מצוי מחוץ לגדריה של תפיסת העולם הדמוקרטית, ושערי חופש הביטוי נעולים בפניו".⁴² ברק, לעומתו, הכיר בכך שהאיסור פוגע בחופש הביטוי. הוא ראה בפגיעה זו פגיעה מוצדקת, שנועדה לתכלית ראויה, ודרש שלא תחרוג מהמידה הדרושה. את שאלת הודאות הקרובה השאיר בצריך עיון.⁴³ בספרות נמתחה ביקורת על היעדר מבחן הסתברותי בעבירות ביטוי, ונטען שיש לבחון בכל עבירה מהו הערך המוגן ואיזה סיכון מצדיק את הגבלת הביטוי.⁴⁴

אפשר לבחון את סעיף 144ב גם לפי מבחני פסקת ההגבלה שבסעיף 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. הסעיף נחקק לפני חוק היסוד ומוגן מפני ביטול מכוח סעיף שמירת הדינים, אבל יש לפרש אותו ברוח חוק היסוד.⁴⁵ תכלית האיסור ראויה: הגנה על כבוד האדם, על השוויון ועל שלום הציבור. שאלת המידתיות מורכבת יותר. לטובת הסעיף עומדות דרישת המטרה, שמצמצמת מאוד את היקפו, ודרישת ההסכמה של היועץ המשפטי. לחובתו עומדות ההגדרה הרחבה של "גזענות" והיעדר כל דרישה הסתברותית. ברק ערך בפרשת אלבה בחינה מעין זו, כשפירש את המילה "דבר" כך שהפגיעה בחופש הביטוי לא תעבור את המידה הדרושה.⁴⁶ לדעתי, עם דרישת התוכן האובייקטיבי הסעיף עומד במבחן המידתיות. בלעדית, כפי שהציע מצא, קשה להצדיק ענישה על אמירה תמימה.

לפי גור-אריה, השאלה אם להפליל ביטויי שנאה משקפת הבדלים תרבותיים במשקל שכל שיטה נותנת לחופש הביטוי לעומת זכויות יסוד אחרות. בארצות הברית התיקון הראשון לחוקה מעניק לחופש הביטוי משקל חוקתי גבוה במיוחד, ולכן אין שם איסור פלילי על ביטויי שנאה אלא רק על מעשים

⁴¹ בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז 871 (1953).

⁴² עניין אלבה, לעיל ה"ש 6, בעמ' 267, 276.

⁴³ שם, בעמ' 294–296.

⁴⁴ אלון הראל "עבירות המגבילות את חופש הביטוי ומבחן 'אפשרות ממשית של נזק': חשיבה מחודשת" משפטים ל 69 (1999); מרדכי קרמיניצר וליאת לבנון-מורג "הגבלת חופש הביטוי בשל חשש לאלימות – על ערכים מוגנים ומבחני הסתברות בעבירות של הסתה להמרדה והסתה לאלימות, בעקבות פרשת כהנא" משפט וממשל ז 305 (2004).

⁴⁵ ס' 8 ו-10 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו; גור-אריה, לעיל ה"ש 14, בעמ' 773.

⁴⁶ עניין אלבה, לעיל ה"ש 6, בעמ' 295–297.

שנעשו ממניע של שנאה. ההנחה היא שעם ביטוי פוגעני מתמודדים באמצעות ביטוי נגדי.⁴⁷ ביטוי מסית מוגבל שם רק כשהוא מכוון להסית לפעולה בלתי חוקית מיידית ועלול להביא לה.⁴⁸ באירופה, לעומת זאת, כבוד האדם הוא ערך חוקתי במשקל גבוה, לעיתים מוחלט, והוא גובר על חופש הביטוי. בגרמניה הסתה נגד חלקי אוכלוסייה היא עבירה לפי סעיף 130 לחוק הפלילי,⁴⁹ ובית הדין האירופי לזכויות אדם קבע שבחברה דמוקרטית ייתכן צורך להגביל ואף למנוע ביטויים שמפיצים, מסיתים, מקדמים או מצדיקים שנאה המבוססת על חוסר סובלנות, ובלבד שההגבלה מידתית.⁵⁰ גם לגישה האירופית יש גבול: בפרשת Perinçek קבע בית הדין שהרשעתו של פוליטיקאי טורקי שהכחיש את רצח העם הארמני אינה מידתית.⁵¹ קנדה נמצאת בתווך: בית המשפט העליון שם אישר את חוקתיות האיסור על קידום שנאה במכוון.⁵²

הקרבה לגישה האירופית ניכרת גם בחוק איסור הכחשת השואה, שנחקק באותה שנה כמו סעיף 144ב. עם זאת, לפי גור-אריה החוק הישראלי שונה מהחוקים האירופיים: עיקרו אינו ההגנה על כבוד הקורבנות והניצולים, אלא מניעת ביטויי אהדה או הזדהות עם פשעי המשטר הנאצי.⁵³ שני החוקים משקפים מגמה של אמצע שנות השמונים: נכונות להשתמש במשפט הפלילי נגד ביטויי שנאה שנתפסו כמסכנים את יסודות המדינה.

ישראל קרובה לגישה האירופית, אבל סעיף 144ב מסווג יותר מהמקבילה הגרמנית, משום שהוא דורש מטרה להסית. את ההצדקה הערכית לגישה זו אפשר למצוא בכתיבתו של ג'רמי וולדרון, שלפיה ביטוי שנאה פוגע במעמד של בני הקבוצה כשווים בחברה, גם כשאנו מוביל לאלימות.⁵⁴ הגישה הזו מתיישבת עם דברי מצא על הביטוי הגזעני כחריג, ועם הדרישה של ברק שהפגיעה בחופש הביטוי לא תחרוג מהמידה הדרושה.

פרק ו: ביקורת והצעות

1. האכיפה ושיקול הדעת של היועץ המשפטי

לפי מרשק-מרום, הגשת כתב אישום בעבירה זו "אינה עניין קל ערך", והתביעה נוהגת בזהירות ומונחית "גם לפי שיקולים ערכיים, ולא רק לפי שיקולים משפטיים".⁵⁵ זהירות כזו מוצדקת. רובינשטיין עצמו כתב, בעת שכיחן כיועץ המשפטי לממשלה, שהמשפט הפלילי "אינו יכול לשמש ככלי העיקרי לחינוך הציבור להתבטאות מתונה".⁵⁶ אבל פרשת תורת המלך מראה את הצד השני. בית המשפט קבע

⁴⁷ גור-אריה, לעיל ה"ש 14, בעמ' 765.

⁴⁸ Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969).

⁴⁹ רובי סיבל "המאבק באנטישמיות והמשפט הבין-לאומי" משפט ועסקים 43, 52–53 (2022).

⁵⁰ Erbakan v. Turkey, App. No. 59405/00 (Eur. Ct. H.R. 2006); גור-אריה, לעיל ה"ש 14, בעמ' 765–766 ה"ש 26.

⁵¹ Perinçek v. Switzerland, 2015-VI Eur. Ct. H.R. 181; גור-אריה, לעיל ה"ש 14, בעמ' 766.

⁵² R. v. Keegstra, [1990] 3 S.C.R. 697.

⁵³ חוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו-1986; גור-אריה, לעיל ה"ש 14, בעמ' 767.

⁵⁴ JEREMY WALDRON, THE HARM IN HATE SPEECH (2012).

⁵⁵ מרשק-מרום, לעיל ה"ש 5, בעמ' 571.

⁵⁶ אליקים רובינשטיין "על חופש הביטוי ועל מדיניות התביעה בעבירות של הסתה לאלימות" הפרקליט מד 5, 10 (1998); עניין סלאח, לעיל ה"ש 23, פס' נז.

שצעדי החקירה היו "רחוקים מהיות משביעי רצון", ובכל זאת לא התערב.⁵⁷ כשדרישת ההסכמה של היועץ המשפטי מצטרפת לביקורת שיפוטית מצומצמת על החלטותיו, כמעט אין ביקורת ממשית על החלטה שלא להעמיד לדין. השופט בך צפה כבר בפרשת אלבה ש"יהיה קשה מאוד לתביעה להוכיח" מטרה להסית כשהדברים על פניהם תמימים.⁵⁸ מספרם הקטן של כתבי האישום מאז מראה שהקושי הזה אינו תיאורטי. הצעתי היא לפרסם הנחיה שתפרט את השיקולים להעמדה לדין לפי סעיף 144ב, ולפרסם החלטות סגירה מנומקות בתיקים שיש בהם עניין ציבורי. כך אפשר יהיה לבחון את המדיניות ולהשוות בין מקרים.

2. עקרון החוקיות

גור-אריה מבקרת את נטייתם של בתי המשפט להשלים בפרשנות תכליתית עבירות שהגדרתן אינה ברורה, ומביאה כדוגמה את עבירת הפרת האמונים בפרשת שבת. לדבריה, כשיסודות העבירה אינם מוגדרים, ההכרעה על היקף האיסור עוברת לבית המשפט, "בסתירה בולטת לעקרון החוקיות".⁵⁹ עבירת ההסתה לגזענות סובלת מבעיה דומה בשתי שכבות. ההגדרה בסעיף 144א משתמשת במונחים פתוחים כמו "ביזוי" ו"גרימת מדנים", ובשאלת היסוד הנפשי אין הכרעה כבר שלושה עשורים. השופט ג'ובראן צדק כשכתב שמצב זה פוגע בדרישה שהחוק הפלילי יהיה ברור, ומקשה על הציבור לדעת מראש מה אסור.⁶⁰

מנגד, סעיף 34כא לחוק קובע שכאשר לחיקוק יש כמה פירושים סבירים לפי תכליתו, יש להכריע לפי הפירוש המקל עם מי שאמור לשאת באחריות פלילית.⁶¹ אפשר לטעון שכל עוד השאלה פתוחה, הסעיף מחייב דווקא שלא להחיל את הלכת הצפיות. זו סיבה נוספת לכך שההכרעה צריכה לבוא מהמחוקק. תיקון קצר של סעיף 144ב, שיקבע במפורש שצפייה ברמה של קרוב לוודאי כמוה כמטרה ויעגן את דרישת התוכן שקבע ברק, יפתור את שתי הבעיות יחד.

3. הרשתות החברתיות

השופט ג'ובראן הזכיר בפרשת תורת המלך את המציאות "שבה דברי הסתה הנכתבים בעט מושחת גוררים אחריהם לא אחת שימוש קטלני בסכין מושחת".⁶² ברשתות החברתיות כל משתמש יכול להפיץ מסר לאלפי אנשים ברגע. לפי השופט מצא, גם פרסום של דבר שחיבר אדם אחר ממלא את היסוד העובדתי,⁶³ ולכן שיתוף של פוסט גזעני עשוי להיחשב "פרסום". כאן שאלת היסוד הנפשי חשובה עוד יותר: מי שמשתף פוסט כזה צופה בדרך כלל את השפעתו, אבל לא תמיד רוצה בה. בלי הכרעה בשאלת הלכת הצפיות קשה לדעת אם מעשה כזה נכנס לגדר העבירה.

⁵⁷ פרשת תורת המלך, לעיל ה"ש 28.

⁵⁸ עניין אלבה, לעיל ה"ש 6, בעמ' 305.

⁵⁹ גור-אריה, לעיל ה"ש 14, בעמ' 768-769; דנ"פ 1397/03 מדינת ישראל נ' שבה, פ"ד נט(4) 385 (2004).

⁶⁰ פרשת תורת המלך, לעיל ה"ש 28, פס' 24 לפסק דינו של השופט ג'ובראן; מרדכי קרמניצר "פרשת אלבה: בירור הלכות הסתה לגזענות" משפטים ל 105, 131 (1999).

⁶¹ ס' 34כא לחוק העונשין.

⁶² פרשת תורת המלך, לעיל ה"ש 28, פס' 13 לפסק דינו של השופט ג'ובראן; מרשק-מרום, לעיל ה"ש 5, בעמ' 573.

⁶³ עניין אלבה, לעיל ה"ש 6, בעמ' 264.

4. דרכים שאינן פליליות

המשפט הפלילי אינו הכלי היחיד. סעיף 7 לחוק-יסוד: הכנסת מאפשר למנוע מרשימה או ממועמד שמסיתים לגזענות להתמודד בבחירות. בפרשת כסיף, שעסקה בבקשה לפסול מועמד, הובהר שהסתה לגזענות נבחנת גם שם כהתנהגות, בלי צורך להוכיח שהביאה לתוצאה, ושהיא נתפסת כביטוי שפוגע בכבוד האדם, בשוויון ובאופייה הדמוקרטי של המדינה.⁶⁴ גם רשם העמותות רשאי לסרב לרשום עמותה שמטרתה ביצוע עבירה לפי סעיף 144ב, או שהיא משמשת מסווה לפעולה כזו.⁶⁵ רובי סיבל מציע להעביר חלק מהמאבק בביטויים אנטישמיים לתביעות אזרחיות, שבהן די במאזן הסתברויות ואין צורך בהוכחה מעבר לספק סביר.⁶⁶ לכלים האלה יש יתרון: הם אינם כרוכים בענישה, ולכן פגיעתם בחופש הביטוי קטנה יותר. אבל הם אינם תחליף מלא לאיסור הפלילי, שמבטא את סלידתה של החברה מהסתה גזענית. לדעתי הם צריכים להשלים את סעיף 144ב, ולא להחליף אותו.

סיכום

עבירת ההסתה לגזענות נחקקה כתגובה לגזענות של תנועת כך, ובפסיקה היא התפתחה לכלי שמגן על כל קבוצה. בשאלת התוכן הפסיקה מצאה איזון: בעקבות הנשיא ברק נדרש שהטקסט עצמו, לפי מובנו לשומע ובהקשרו, יבטא הסתה, וכך נמנעת ענישה על מחשבה בלבד. פרשות העברי וסלאח מראות שהמבחן גמיש מספיק כדי לתפוס גם סיסמה קצרה וגם רמז לעלילת דם.

בשאלת היסוד הנפשי הדין עדיין לא ברור. המחלוקת בין מצא לבין ברק ב-1996 חזרה כמעט כלשונה בין ג'ובראן לבין רובינשטיין ב-2015, ולא הוכרעה. יחד עם דרישת ההסכמה של היועץ המשפטי והביקורת השיפוטית המצומצמת, אי-הוודאות הזו משאירה את היקף העבירה בידי רשויות התביעה. הצעתי היא להכריע בחקיקה: להחיל את הלכת הצפיות, לעגן את דרישת התוכן האובייקטיבי ולשמור על הסייגים שבסעיף 144ג. כך תוכל העבירה להגן על כבוד האדם ועל השוויון בלי לפגוע בחופש הביטוי יותר מהנדרש.

הצורך בהכרעה ילך ויגבר. רוב הביטויים הגזעניים כיום אינם מתפרסמים במאמרים הלכתיים או בדרשות מול קהל, אלא ברשתות החברתיות, בשיתופים ובתגובות קצרות. במקרים אלה כמעט אין אפשרות להוכיח מה רצה המפרסם, והשאלה אם די בכך שצפה את התוצאה תהיה לעיתים קרובות השאלה המכרעת. עבירה שנולדה נגד תנועה פוליטית מאורגנת צריכה היום להתמודד עם הפצה מבוזרת, והכלים הפרשניים שעוצבו לפני שלושים שנה אינם מספיקים לכך בלי הבהרה של המחוקק.

⁶⁴ א"ב 1806/19 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 נ' כסיף (נבו 18.7.2019).

⁶⁵ דוד א' פרנקל וצבי פרנקל דיני עמותות בישראל פרק א (2025).

⁶⁶ סיבל, לעיל ה"ש 49.

רשימה ביבליוגרפית

חקיקה ואמנות

- חוק-יסוד: הכנסת.
- חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.
- חוק העונשין, התשל"ז-1977.
- חוק העונשין (תיקון מס' 20), התשמ"ו-1986.
- חוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו-1986.
- אמנה בין-לאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית, כ"א 25, 547 (נפתחה לחתימה ב-1966).

פסיקה ישראלית

- א"ב 1806/19 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 נ' כסיף (נבו 18.7.2019).
- בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז 871 (1953).
- בג"ץ 399/85 כהנא נ' הוועד המנהל של רשות השידור, פ"ד מא(3) 255 (1987).
- בג"ץ 2684/12 י"ב בחשוון התנועה לחיזוק הסובלנות בחינוך הדתי נ' היועץ המשפטי לממשלה (נבו 9.12.2015).
- דנ"פ 1397/03 מדינת ישראל נ' שבח, פ"ד נט(4) 385 (2004).
- דנ"פ 8613/96 ג'בארין נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(5) 193 (2000).
- ע"ב 1/88 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים-עשרה, פ"ד מב(4) 177 (1988).
- ע"פ 99/14 מדינת ישראל נ' מליסרון בע"מ (נבו 25.12.2014).
- ע"פ 2831/95 אלבה נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(5) 221 (1996).
- ע"פ 6696/96 כהנא נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(1) 535 (1998).
- ע"פ 9818/01 ביטון נ' סולטן, פ"ד נט(6) 554 (2005).
- ע"פ (מחוזי י-ם) 8612/04 העברי נ' מדינת ישראל (נבו 4.5.2005).
- רע"פ 7669/15 מחאג'נה נ' מדינת ישראל (נבו 18.4.2016).
- ת"פ (מחוזי י-ם) 251/94 מדינת ישראל נ' אלבה (נבו 12.4.1995).

ספרים ומאמרים

- דוד א' פרנקל וצבי פרנקל דיני עמותות בישראל (2025).
- מרים גור-אריה "זכויות אדם והמשפט הפלילי המהותי" משפטים נ 759 (2021).
- אלון הראל "עבירות המגבילות את חופש הביטוי ומבחן 'אפשרות ממשית של נזק': חשיבה מחודשת" משפטים ל 69 (1999).
- דנה מרשק-מרום "התפתחותה של הסתה" 75 שנות עצמאות במשפט 570 (דפנה ברק-ארז עורכת ראשית 2023).
- רובי סיבל "המאבק באנטישמיות והמשפט הבין-לאומי" משפט ועסקים כה 43 (2022).
- גיל עשת "הלכת הצפיות: יסודות של ודאות מול שיקול-דעת שיפוטי על רקע תיקון 39 לחוק העונשין" עלי משפט ג 617 (2003).
- רות קנאי ורוני רוזנברג "הלכת הצפיות ועבירת הניסיון: הילכו שתיהן יחדיו?" ספר יעקב וינרוט 475 (גרשון גונטובניק, אברהם וינרוט וחיים זיכרמן עורכים 2021).
- מרדכי קרמניצר "פרשת אלבה: בירור הלכות הסתה לגזענות" משפטים ל 105 (1999).

מרדכי קרמיצר וליאת לבנון-מורג "הגבלת חופש הביטוי בשל חשש לאלימות – על ערכים מוגנים ומבחני הסתברות בעבירות של הסתה להמרדה והסתה לאלימות, בעקבות פרשת כהנא" **משפט וממשל** ז' 305 (2004).

יורם רבין ויניב ואקי **דיני עונשין** א (מהדורה שלישית 2014).

אליקים רובינשטיין "על חופש הביטוי ועל מדיניות התביעה בעבירות של הסתה לאלימות" **הפרקליט** מד 5 (1998).

מקורות זרים

JEREMY WALDRON, THE HARM IN HATE SPEECH (2012).

Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969).

Erbakan v. Turkey, App. No. 59405/00 (Eur. Ct. H.R. 2006).

Perinçek v. Switzerland, 2015-VI Eur. Ct. H.R. 181.

R. v. Keegstra, [1990] 3 S.C.R. 697.